

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel;

c) Serviços comuns e especiais de engenharia (art. 6º, XXI): percebe-se que obras, conforme visto acima, são privativas de arquiteto e engenheiro e inovam o espaço físico ou alteram substancialmente um imóvel já existente; serviços de engenharia são residuais, ou seja, tudo que não for obra, será serviço de engenharia.

Os serviços de engenharia possuem três características.

- Atividade para obter utilidade intelectual ou material: como exemplo, pode-se citar a modernização do sistema de climatização de uma repartição pública, que é um serviço que tem características intelectuais (projeto) e materiais (execução), mas não inova o espaço físico nem altera substancialmente o imóvel.

- Privativas de arquiteto, engenheiro ou técnico especializado: como exemplo, a pintura de uma parede, que deve ser realizada por um profissional com conhecimento (técnico especializado), mas não inova o espaço físico nem altera substancialmente o imóvel.

- Não são classificadas como obra: por fim, os serviços de engenharia são residuais, ou seja, tudo que não for obra, será serviço de engenharia.

c.1) Serviço comum de engenharia: são ações objetivamente padronizáveis, acompanhados por profissional habilitado, com preservação das características originais dos bens. Ex.: o metro quadrado de colocação de revestimento cerâmico (é algo padronizável e que não altera as características de um imóvel).

- Concorrência e pregão: os serviços comuns de engenharia podem ser licitados pelas modalidades concorrência e pregão.

Trata-se de decisão discricionária, ou seja, cabe ao órgão público decidir por qual modalidade licitará o serviço comum de engenharia.

c.2) Serviço especial de engenharia: são ações que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não são serviço comum de engenharia – serviços de engenharia cujas características dependem de uma capacidade técnica especial do profissional, de tal forma que não seria possível descrevê-lo objetivamente.

- Concorrência (apenas): os serviços especiais de engenharia somente podem ser licitados pela modalidade concorrência (não por pregão).

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que,

não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do *caput* deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

- a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;
- b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da alínea "a" deste inciso;

→ *Critérios de julgamento*: a modalidade concorrência admite todos os critérios de julgamento, com exceção do maior lance.

Logo, a licitação na modalidade concorrência poderá adotar qualquer um dos seguintes critérios de julgamento – estudaremos os critérios adiante, em tópico próprio:

- *Menor preço.*
- *Melhor técnica ou conteúdo artístico.*
- *Técnica e preço.*
- *Maior retorno econômico.*
- *Maior desconto.*
- ~~*Maior lance.*~~

5.3. Pregão

Pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, incluindo os serviços comuns de engenharia, cujo critério de julgamento deve ser o menor preço ou o maior desconto – art. 6º, XLI.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

a) Hipóteses (utiliza-se o pregão): o pregão destina-se para as licitações que tenham os seguintes objetos:

- *Serviços comuns de engenharia = pregão ou concorrência*: vistos no tópico anterior, são serviços objetivamente padronizáveis, acompanhados por profissional habilitado, com preservação das características originais dos bens.

Aqui a Administração pública pode optar (ato discricionário) em utilizar a modalidade pregão ou concorrência.

- *Bens e serviços comuns = somente pregão (art. 6º, XIII, e art. 29)*: bens e serviços comuns são aqueles que possuem padrões de desempenho e de qualidade que podem ser definidos objetivamente por meio de especificações usuais de mercado.

Tratando-se de bens e serviços comuns, a utilização do pregão é obrigatória, vale dizer, não pode ser utilizada outra modalidade de licitação.

Exemplo1: a aquisição de *notebook*, *smartphone* ou *smart tv*, produtos que possuem especificações usuais de mercado, como o tamanho e o brilho da tela, a qualidade da câmera, a velocidade do processador, a quantidade de memória... – tratam-se de características que os fabricantes e as lojas utilizam quando oferecem esses produtos.

Exemplo2: serviço de pintura de paredes, que, via de regra, adota como referência a quantidade de metros quadrados a serem pintadas – também é uma especificação usual do mercado.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea "a" do inciso XXI do *caput* do art. 6º desta Lei.

b) Não cabe pregão (art. 29, púnico): por outro lado, o pregão não pode ser utilizado para as licitações que tenham os seguintes objetos:

- *Bens e serviços especiais.*
- *Obras.*
- *Serviços especiais de engenharia.*
- *Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.*
- *Locações imobiliárias.*
- *Alienações.*

→ Critérios de julgamento: a modalidade pregão os critérios de julgamento menor preço e maior desconto:

- *Menor preço.*
- ~~*Melhor técnica ou conteúdo artístico.*~~
- ~~*Técnica e preço.*~~
- ~~*Maior retorno econômico.*~~
- *Maior desconto.*
- ~~*Maior lance.*~~

5.4. Concurso

Concurso é a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, sendo concedido um prêmio ou uma remuneração ao vencedor – art. 6º, XXXIX.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXXIX - concurso: modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor;

Atenção: não confundir com concurso público, que é destinado para selecionar pessoas que trabalharão na Administração pública.

a) Trabalho técnico, científico ou artístico: o concurso é a modalidade de licitação cujo objeto é a escolha de trabalho técnicos, científicos ou artísticos.

Exemplo: a contratação de um projeto arquitetônico para a construção do novo prédio da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul/SC – nesse caso, quando o concurso for destinado à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à Administração pública todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes (art. 30, parágrafo único).

b) Princípio do julgamento objetivo é flexibilizado: no concurso, o objeto guarda características especiais, exigindo uma análise um pouco subjetiva.

Justamente por isso é comum dizer que, no concurso, o princípio do julgamento objetivo é flexibilizado, uma vez que o julgamento poderá ter uma análise com um pouco de subjetividade, porém sem que haja arbitrariedade.

c) Características: a modalidade concurso possui as seguintes características:

- Escolha de trabalho técnico, científico ou artístico.
- Concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor.

d) Edital (art. 30): o concurso obviamente deve observar as regras e condições previstas em edital, o qual deve indicar, obrigatoriamente:

- Qualificação exigida dos participantes.
- Diretrizes e formas de apresentação do trabalho.
- Condições de realização e o prêmio ou a remuneração a ser concedida ao vencedor.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 30. O concurso observará as regras e condições previstas em edital, que indicará:

- I - a qualificação exigida dos participantes;
- II - as diretrizes e formas de apresentação do trabalho;
- III - as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor.

Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à Administração Pública, nos termos do art. 93 desta Lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes.

→ Critérios de julgamento: no concurso somente pode ser utilizado um critério de julgamento, qual seja, melhor técnica ou conteúdo artístico:

- *Menor preço.*

- *Melhor técnica ou conteúdo artístico.*
- *Técnica e preço.*
- *Maior retorno econômico.*
- *Maior desconto.*
- *Maior lance.*

5.5. Leilão

O leilão é modalidade de licitação para alienação (venda) de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance – art. 6º, XL.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XL - leilão: modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance;

a) Alienar bem móvel ou imóvel: o leilão serve para a Administração pública alienar (vender) bens para terceiros, que podem ser móveis ou imóveis.

- *Venda de bem imóvel;*
- *Venda de bem móvel inservível ou legalmente apreendido.*

Exemplo1: a Prefeitura de Guaramirim possui diversos veículos usados que estão sobrando porque adquiriu veículos novos; os veículos usados podem ser leiloados.

Exemplo2: o Estado possui um terreno com um prédio, onde funcionava uma escola, atualmente sem utilização e gerando despesas de manutenção e cuidados; resolve então, alienar esse imóvel. Essa alienação deverá ser realizada por meio de leilão.

b) Condução do leilão: a modalidade leilão pode ser conduzida tanto por um leiloeiro oficial quanto por um servidor designado.

- *Leiloeiro oficial (leilão comum):* leiloeiros oficiais são pessoas habilitadas e credenciadas nas juntas comerciais – são particulares que colaboram com o poder público, assim como os tradutores oficiais, intérpretes e outros particulares que colaboram com o Estado.

O leilão realizado por leiloeiro oficial é chamado de leilão comum.

- *Servidor designado (leilão administrativo):* trata-se de um servidor público designado pela pela Autoridade competente da Administração pública.

O leilão realizado por servidor público é conhecido como leilão administrativo.

→ *Critérios de julgamento:* o leilão é a única modalidade de licitação na qual se utiliza o critério de julgamento do maior lance:

- *Menor preço.*
- *Melhor técnica ou conteúdo artístico.*
- *Técnica e preço.*
- *Maior retorno econômico.*

- ~~Maior desconto.~~
- ~~Maior lance.~~

5.6. Diálogo Competitivo

O diálogo competitivo é a modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração pública realiza diálogos, com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos – art. 6º, XLII.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XLII - diálogo competitivo: modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos;

Exemplo: digamos que uma região do nosso Estado é bastante isolada em virtude das condições do seu relevo, inviabilizando o desenvolvimento econômico e social. Então a Administração pública resolve fazer uma licitação para tentar encontrar uma forma para resolver a questão, interligando essa região às demais para resolver esse problema de logística; todavia, como ela irá descrever, no edital, o que ela quer licitar se ainda não há uma solução? É aqui que entra o diálogo competitivo.

5.6.1. Hipóteses (art. 32, caput)

O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação que somente pode ser adotada em casos muito específicos – trata-se, na verdade, de uma forma excepcional de licitação.

Por isso, exige-se a presença das seguintes situações para que o diálogo competitivo possa ser adotado.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a Administração:

I - vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições:

- a) inovação tecnológica ou técnica;
- b) impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e
- c) impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração;

II - verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos:

- a) a solução técnica mais adequada;
- b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida;
- c) a estrutura jurídica ou financeira do contrato;

III - (VETADO).

§ 1º [...]

a) Objeto – inovação técnica ou tecnológica: o objeto que a Administração pública quer contratar exige inovação técnica ou tecnológica, sendo que as soluções disponíveis no mercado não atendem à necessidade da Administração, exigindo a realização de adaptações.

Ainda, a situação deve ser tão complexa que a Administração não é capaz de definir adequadamente as especificações.

Portanto, o objeto da contratação deve envolver:

- *Inovação tecnológica ou técnica;*
- *Impossibilidade de adaptação de soluções disponíveis no mercado;*
- *Impossibilidade de definir as especificações técnicas com precisão.*

b) Definir meios e alternativas: aqui já se está pensando na solução – deve estar presente a necessidade de identificar meios e alternativas que possam satisfazer as necessidades da Administração pública.

Portanto, a Administração já deve pensar que o diálogo competitivo apontará:

- *Solução técnica mais adequada;*
- *Requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida;*
- *Estrutura jurídica ou financeira do contrato.*

Exemplo: considerando a mesma situação antes mencionada, a Administração pública não sabe como resolver o problema de acesso à região do nosso Estado que está isolada. Utiliza, então, o diálogo competitivo porque as soluções disponíveis no mercado não atendem à necessidade e sequer é possível definir as especificações técnicas no edital. A Administração também percebe que os outros métodos de disputa não resolvem o problema – a concorrência e as outras modalidades não são aptas para o caso. Sobra, então, adotar o diálogo competitivo, pensando na solução técnica que será mais adequada, nos requisitos para concretizar a solução e na estrutura (jurídica ou financeira) do contrato.

5.6.2. Etapas (art. 32, § 1º)

O diálogo competitivo possui cinco etapas, que abaixo que seguem.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 32. [...]

§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições:

I - a Administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação;

II - os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos;

III - a divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada;

IV - a Administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento;

V - a fase de diálogo poderá ser mantida até que a Administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades;

VI - as reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo;

VII - o edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas;

VIII - a Administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo, não inferior a 60 (sessenta) dias úteis, para todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso II deste parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto;

IX - a Administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas;

X - a Administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado;

XI - o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão;

XII - (VETADO).

a) Divulgação do edital com as necessidades e exigências prévias: a Administração pública divulga o edital (no sítio eletrônico oficial) apresentando as suas necessidades e as exigências que já estão definidas – em momento posterior, novas necessidades e exigências podem surgir, conforme os diálogos vão sendo realizados.

- 25d úteis: o edital deverá prever um prazo mínimo de 25 dias úteis para que os interessados possam manifestar interesse em participar do diálogo competitivo.

b) Pré-seleção dos licitantes: a Administração selecionará todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos no edital – quem preencher, participará; quem não preencher todos os requisitos, não será selecionado e não poderá participar das próximas etapas.

c) Realização dos diálogos: aqui a Administração pública e os licitantes selecionados realizarão diálogos para a escolha de uma solução.

Essa fase poderá ser mantida até que a Administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. Portanto, não existe um prazo definido para encerrar os diálogos – podem ocorrer vários diálogos (reuniões) até que se chegue a uma solução.

Três peculiaridades desta fase: (i) os diálogos (reuniões) realizados devem ser registrados em ata e gravados em áudio e vídeo; (ii) a Administração não pode revelar, para outros licitantes, as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento; e (iii) é vedada a divulgação de informações de modo discriminatório, de forma que possam implicar vantagem para algum licitante (ex.: a Administração pública realizou alguns estudos técnicos e revela os resultados somente para um licitante; não pode).

d) Divulgação da solução encontrada: finalizados os debates, a Administração pública declara que o diálogo foi concluído e junta aos autos do processo licitatório os registros e as gravações. Até aqui não há competição entre os licitantes: eles e a Administração pública estavam apenas conversando, debatendo, buscando identificar uma solução para o problema existente.

- Edital: encerrado o diálogo, a Administração deve publicar um novo edital, agora com foco na fase competitiva. Esse edital deverá conter: (i) a solução encontrada, que atenda às

necessidades; e (ii) os critérios objetivos a serem utilizados para seleção da proposta mais vantajosa.

e) Realização da fase competitiva: por fim, com a publicação do edital mencionado acima, inicia a fase competitiva, onde os licitantes apresentarão suas propostas para a execução da solução encontrada.

- 60d úteis: o edital deverá prever um prazo mínimo de 60 dias úteis para que os licitantes pré-selecionados apresentem suas propostas.

5.6.3. Comissão de Contratação

Conforme já foi visto anteriormente, o diálogo competitivo é, obrigatoriamente, conduzido por uma comissão de contratação, que possui as peculiaridades que seguem.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 32. [...]

§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições:

XI - o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão;

§ 2º Os profissionais contratados para os fins do inciso XI do § 1º deste artigo assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam configurar conflito de interesses.

a) 3 servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente: os membros dessa comissão de contratação devem ser, obrigatoriamente, servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração pública.

b) Contratação de assessoramento técnico: é admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão.

Esses profissionais assinarão termo de confidencialidade e deverão abster-se de realizar atividades que possam configurar conflito de interesses (art. 32, § 2º).

6. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Os critérios de julgamento são a forma de aferir a proposta mais vantajosa para a Administração pública.

a) Quais são? Os critérios são os seguintes:

- *Menor preço;*
- *Maior desconto;*
- *Melhor técnica ou conteúdo artístico;*
- *Técnica e preço;*
- *Maior lance (leilão);*
- *Maior retorno econômico.*

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

- I - menor preço;
- II - maior desconto;
- III - melhor técnica ou conteúdo artístico;
- IV - técnica e preço;
- V - maior lance, no caso de leilão;
- VI - maior retorno econômico.

6.1. Menor Preço e Maior Desconto

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preço considerará o menor dispêndio para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação.

§ 1º Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento.

§ 2º O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos.

a) Menor dispêndio (art. 34): os critérios do menor preço e do maior desconto são conhecidos como critério do menor dispêndio. Isso porque, nos dois casos, o resultado será o menor custo para a Administração pública, mas, claro, desde que, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital da licitação.

Portanto, aqui a proposta mais vantajosa será aquela que:

- *Atendidos aos parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação;*
- *Gerar o menor dispêndio para a Administração pública.*

b) Diferença: apesar do ponto comum – menor dispêndio –, há diferença entre os critérios do menor preço e do maior desconto.

- Menor preço: aqui a proposta mais vantajosa é aquela que apresentar o menor valor nominal, literal.

Exemplo: um licitante ofereceu o ar-condicionado do tipo split por R\$ 1.200,00, outro por R\$ 1.110,00 e um terceiro por R\$ 1.100,00 – este será o vencedor do certame.

- Maior desconto: no critério do maior desconto a proposta vencedora é identificada de forma indireta – vence quem ofertar o maior desconto sobre um preço de referência.

Exemplo: existem várias tabelas que trazem valores de referência de medicamentos. Assim, numa licitação para a compra de medicamentos, a Administração pública pode utilizar como critério de julgamento o maior desconto sobre a tabela “X”; portanto, se o medicamento custa R\$ 50,00 naquela tabela, vence quem ofertar o maior desconto sobre o valor de referência. Digamos que uma empresa oferece 4% de desconto (equivalente a R\$ 48,00) outra oferece 7% (equivalente a R\$ 46,50) – esta será a vencedora do certame.

c) Parâmetros mínimos de qualidade: como dito, devem ser atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos pelo Poder público no edital da licitação.

Exemplo: se a Administração quer adquirir um ar-condicionado que resfrie, mas que seja do tipo split, não adianta oferecer ar-condicionado de janela, mesmo que com um preço bastante inferior – se a proposta não atender ao mínimo, ela fica fora.

Além do mais, se a proposta for melhor que o mínimo, isso não trará vantagens para o licitante: no caso acima, o licitante que oferecer um ar split que, além de resfriar, também esquenta, não terá vantagens em relação aos demais – deve atender ao mínimo, e o que supera o mínimo, não traz vantagens.

d) Custos indiretos objetivamente mensuráveis (art. 34, § 1º): no menor dispêndio a Administração pública também pode considerar os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação, impacto ambiental e outros fatores vinculados ao ciclo de vida do objeto licitado.

Exemplo: para adquirir um veículo, o Poder público pode considerar no menor preço ou maior desconto o custo da manutenção preventiva nos anos de utilização que pretende ficar com esse veículo.

e) Critério técnica e preço (art. 34, caput): em casos excepcionais, os critérios do menor preço e do maior desconto também podem ser considerados no critério de julgamento técnica e preço (veremos adiante).

f) Modalidades: por fim, os critérios do menor preço e do maior desconto são compatíveis com as modalidades pregão e concorrência.

- Pregão: o julgamento sempre é realizado pelo menor preço ou maior desconto;

- Concorrência: o julgamento é compatível com o menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico;

- ~~Concurso~~ (o concurso é necessariamente licitado por melhor técnica ou conteúdo artístico);
- ~~Leilão~~ (o leilão adota sempre o maior lance);
- ~~Diálogo competitivo~~ (o diálogo competitivo é incompatível com aferição objetiva e ocorre segundo critérios definidos no edital).

6.2. Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores.

Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o *caput* deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística.

a) Proposta técnica ou artística: o julgamento pelo critério da melhor técnica ou conteúdo artístico considera apenas as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes.

b) Prêmio ou remuneração: no critério melhor técnica ou conteúdo artístico, os licitantes não apresentam uma proposta de preço – o “preço” é estabelecido pela Administração: será um prêmio ou remuneração.

Aos licitantes cabe apenas apresentar a parte técnica ou artística.

Exemplo 1: a Administração pública organiza uma competição de futebol amador, fixando o prêmio ou a remuneração que serão concedidos aos primeiros colocados; se forem prêmios bons, com certeza aparecerão times bons, aumentando a competitividade e gerando um espetáculo melhor para os espectadores.

Exemplo 2: o Poder público quer licitar um projeto arquitetônico para a realização de uma obra.

c) Modalidades: o critério da melhor técnica ou conteúdo artístico é compatível com as modalidades concorrência e concurso.

- ~~Pregão~~ (o julgamento sempre é realizado pelo menor preço ou maior desconto);
- Concorrência: o julgamento é compatível com o menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico;
- Concurso: o concurso é sempre licitado por melhor técnica ou conteúdo artístico;
- ~~Leilão~~ (o leilão adota sempre o maior lance);
- ~~Diálogo competitivo~~ (o diálogo competitivo é incompatível com aferição objetiva e ocorre segundo critérios definidos no edital).

6.3. Técnica e Preço

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta.

§ 1º O critério de julgamento de que trata o *caput* deste artigo será escolhido quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para contratação de:

- I - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado;
- II - serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação;
- III - bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação;
- IV - obras e serviços especiais de engenharia;

V - objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação.

§ 2º No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, na proporção máxima de 70% (setenta por cento) de valoração para a proposta técnica.

§ 3º O desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88 desta Lei e em regulamento.

a) Maior pontuação: o julgamento pelo critério da técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta.

Exemplo: para compreender esse critério de julgamento, melhor ter um exemplo em mente – imagine que você quer fazer uma viagem para conhecer o nordeste brasileiro, sendo que há várias agências de turismo que oferecem esse pacote. Para decidir com qual agência contratar, você pede às agências que apresentem dois envelopes: um com as atrações incluídas no pacote, mas sem valores (hospedagem, alimentação, serviços e comodidades, passeios...) e outro apenas com o valor do pacote de viagem.

Para escolher, você define critérios para dar notas para o primeiro (atrações) e o segundo (preço) envelopes. Depois, basta fazer uma tabela, atribuir as notas, fazer a média e definir o vencedor.

b) Duas propostas: portanto, na adoção desse critério de julgamento, os licitantes apresentarão duas propostas:

- Proposta técnica; e
- Proposta de preço.

c) Ponderação: a Administração pública deverá definir uma ponderação entre as notas atribuídas à proposta técnica e à proposta de preço, ou seja, definir qual será o “peso” das notas de cada envelope para a escolha da melhor proposta.

- Máximo de 70% para técnica: a proposta técnica será valorada em, no máximo, 70%. Ou seja, se a proposta técnica tiver peso 70, a proposta de preço terá peso de 30.

- Preço é livre: percebe-se que a NLLC não colocou um percentual máximo para a ponderação em favor do preço; logo, conclui-se que nada impede uma ponderação de, por exemplo, 95% em favor do preço.

d) Situações: o critério de técnica e preço somente pode ser adotado para as seguintes contratações:

- *Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado:* emissão de pareceres, consultorias, defesa de causas judiciais, treinamento de pessoal... São serviços em que o componente humano faz muita diferença;
- *Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação;*
- *Bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação;*
- *Obras e serviços especiais de engenharia;*
- *Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação:* são objetos em que cada licitante poderá ter o seu método próprio, como, por exemplo, a construção de uma pista olímpica de atletismo – há diferentes empresas, cada uma com as suas tecnologias, mas todas elas vão chegar ao resultado desejado pela Administração.

e) Modalidades: o critério de julgamento da técnica e preço é compatível unicamente com a modalidade concorrência.

- ~~Preço~~ (o julgamento sempre é realizado pelo menor preço ou maior desconto);
- Concorrência: o julgamento é compatível com o menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico;
- ~~Concurso~~ (o concurso é sempre licitado por melhor técnica ou conteúdo artístico);
- ~~Leilão~~ (o leilão adota sempre o maior lance);
- ~~Diálogo competitivo~~ (o diálogo competitivo é incompatível com aferição objetiva e ocorre segundo critérios definidos no edital).

f) Diferença = melhor técnica ou conteúdo artístico X técnica e preço: os critérios de julgamento da melhor técnica ou conteúdo artístico e da técnica e preço têm em comum o fato de haver uma análise do componente técnico da proposta; mas há diferença.

- Melhor técnica ou conteúdo artístico: aqui há somente proposta técnica.
- Técnica e preço: aqui há proposta técnica e proposta de preço.

6.4. Maior Retorno Econômico

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato.

§ 1º Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata o *caput* deste artigo, os licitantes apresentarão:

I - proposta de trabalho, que deverá contemplar:

- a) as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realização ou fornecimento;
- b) a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária;

II - proposta de preço, que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária.

§ 2º O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado.

§ 3º Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço.

§ 4º Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência:

I - a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado;

II - se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis.

a) Contrato de eficiência (art. 6º, LIII): o critério de julgamento do maior retorno econômico será utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência.

Nesse critério, será considerada a maior economia para a Administração pública, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato.

Exemplo: um órgão público possui uma conta de energia elétrica bastante elevada e um estudo indica que algumas obras no prédio gerarão economia, como colocação de novas janelas, modificação do sistema de ar-condicionado, adequação do sistema de iluminação...

A Administração pública, então, lança um edital para contratar uma empresa para fazer tais obras, mas define que a remuneração da empresa será proporcional à economia efetivamente gerada na conta de energia elétrica – isso é o contrato de eficiência.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

LIII - contrato de eficiência: contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada;

b) Peculiaridades: o critério do maior retorno econômico possui as seguintes características:

- a melhor proposta será aquela que gerar a maior economia para a Administração;
- a remuneração do licitante incide, de forma proporcional, sobre a economia efetivamente alcançada na execução do contrato.

c) Duas propostas: no critério do maior retorno econômico os licitantes também apresentam duas propostas:

- Proposta de trabalho: nessa proposta deverão indicar as obras e serviços que serão realizados e os bens que serão fornecidos, bem como os prazos de realização ou fornecimento, e, ainda, a economia que se estima gerar;
- Proposta de preço: o preço deve corresponder a um percentual sobre a economia que se estima gerar.

Exemplo: na proposta de trabalho a empresa diz que executará tais obras e/ou serviços, os quais gerarão uma economia de R\$ 10.000,00 mensais na conta de energia elétrica; na proposta de preço, ela menciona que vai cobrar 25% dessa economia como remuneração (R\$ 2.500,00 por mês).

d) Vencedor da licitação: o vencedor da licitação será aquele que gerar o maior retorno econômico para a Administração pública.

No exemplo acima, o retorno econômico para o Poder público será de R\$ 7.500,00 mensais.

e) Modalidades: o critério da melhor técnica ou conteúdo artístico é compatível com as modalidades concorrência e concurso.

- Pregão (o julgamento sempre é realizado pelo menor preço ou maior desconto);
- Concorrência: o julgamento é compatível com o menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico;
- Concurso (o concurso é sempre licitado por melhor técnica ou conteúdo artístico);
- Leilão (o leilão adota sempre o maior lance);
- Diálogo competitivo (o diálogo competitivo é incompatível com aferição objetiva e ocorre segundo critérios definidos no edital).

6.5. Maior Lance

a) Maior lance = leilão: o maior lance é o critério de julgamento exclusivo do leilão.

O maior lance e o leilão são casados, fiéis e inseparáveis – o leilão somente admite o maior lance; e o maior lance somente é cabível no leilão.

O vencedor será aquele que apresentar o maior valor pelo objeto que está sendo licitado.

b) Modalidades: o critério da melhor técnica ou conteúdo artístico é compatível com as modalidades concorrência e concurso.

- ~~Pregão~~ (o julgamento sempre é realizado pelo menor preço ou maior desconto);
- ~~Concorrência~~ (o julgamento é compatível com o menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico);
- ~~Concurso~~ (o concurso é sempre licitado por melhor técnica ou conteúdo artístico);
- Leilão: o leilão adota sempre o maior lance;
- ~~Diálogo competitivo~~ (o diálogo competitivo é incompatível com aferição objetiva e ocorre segundo critérios definidos no edital).

7. QUESTÕES

- 01) ()** A licitação destina-se a escolher com quem a Administração pública irá contratar, formalizando um contrato administrativo posterior.
- 02) ()** Os princípios da isonomia, igualdade e competitividade comportam uma série de flexibilizações, dentre as quais estão os critérios de desempate e a margem de preferência.
- 03) ()** A adjudicação compulsória é um princípio implícito que garante ao vencedor do certame o direito de assinar o contrato administrativo com o Poder público.
- 04) ()** Um dos objetivos de uma licitação é assegurar a contratação mais barata por parte da Administração pública.
- 05) ()** Todos os agentes públicos designados para trabalhar com licitações devem ter qualificação para tanto.
- 06) ()** A licitação será conduzida por agente de contratação, que deve ser servidor efetivo ou empregado público do quadro permanentes da Administração Pública.
- 07) ()** Concorrência é a modalidade de licitação para contratação de obras, bens e serviços especiais e comuns.
- 08) ()** Para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico deve ser utilizada a modalidade concurso, na qual o vencedor receberá prêmio ou remuneração.
- 09) ()** O leilão é a modalidade de licitação para a aquisição de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance.
- 10) ()** Para a utilização da modalidade diálogo competitivo, o objeto a ser contratado pela Administração pública exige inovação técnica ou tecnológica, sendo que as soluções disponíveis no mercado não atendem à necessidade da Administração.